

1500675-91.2020.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... lhe contaram que ele era conhecido por tráfico. Relatou que indagado, o indivíduo disse que estava transportando o entorpecente e estava o levando para outro local; que perguntaram a residência de onde ele havia saído, e ele os acompanhou até a residência, onde foi encontrado um casal; que, feitas as buscas, apreenderam petrechos para o fim de tráfico, uma prensa, um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500675-91.2020.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500675-91.2020.8.26.0581

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2154529/2020 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 12086707 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 584/20/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2154529 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

AUGUSTO JOSÉ PEDROSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de AUGUSTO JOSÉ PEDROSO e RODRIGO DOMINGUES ALBUQUERQUE, já qualificados nos autos, como incurso no art. 33, caput, e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 (LD), bem como no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), porque, em 25 de junho de 2020, por volta das 11h27min, na Rua Francisco Tedesco, 05 - Cohab II e na Rua Leonardo Marcolan, 85 - São Geraldo, nesta cidade e Comarca de São Manuel, juntamente com a adolescente Maria Eduarda Palombarini de Oliveira, traziam consigo e tinham em depósito, para a venda ou entrega ao consumo de terceiros, 1578,3 gramas de cocaína, 981,16 gramas de "crack", 01 (um) tijolo e meio de maconha e 01 (uma) porção a granel, contendo massa líquida de 938,39 gramas, 01 (um) liquidificador com resquícios de cocaína, além de 01 (uma) prensa, 02 (dois) rolos

de fita adesiva, 01 (um) copo plástico, 01 (uma) faca, 05 (cinco) comprovantes de depósitos, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (uma) moto Honda-CG 150 sport, de placas DWU-4642, além da quantia de R\$ 103,00 (cento e trinta reais).

Consta da denúncia que os policiais militares receberam informações de que, em uma casa situada na Rua Leonardo Marcolan, no bairro São Geraldo, havia o preparo de entorpecentes para a prática do tráfico ilícito; que também receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo teria saído do mesmo endereço conduzindo uma motocicleta e que levava os entorpecentes. Ao se dirigirem às proximidades do local, encontraram o acusado Augusto, em quem realizaram busca pessoal, tendo encontrado, em sua mochila, variadas cocaína e "crack" a granel. Ao ser indagado pelos policiais, Augusto afirmou que havia saído da residência situada na Rua Leonardo Marcolan, número 85 e transportava os entorpecentes para entregar para uma mulher, bem como que iria passar em sua própria residência (Rua Francisco Tedesco, 05 - Cohab II) para buscar mais drogas. Os policiais, na companhia do acusado, se dirigiram até o endereço de onde ele saiu com a motocicleta Honda CG; ao adentrarem o recinto, encontraram o acusado Rodrigo e a adolescente Maria Eduarda; ao realizarem buscas no local, encontraram as demais drogas, petrechos e objetos descritos na denúncia; novamente indagados, os acusados mantiveram-se em silêncio, mas a adolescente afirmou que o local era utilizado para o manuseio de entorpecentes, que eram entregues aos traficantes do município, além de observar que movimentavam R\$11.000,00 (onze mil reais) por semana.

Auto de prisão em flagrante às fls. 7/9.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 151/153.

Notificados (fls. 222 e 224), os acusados apresentaram defesa prévia às fls. 218/219 e 263/264.

Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fl. 277 e 296/297).

Em audiências de instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 343/344 e 370/372).

Em alegações finais, a d. representante do Ministério Público requer a condenação, nos termos da denúncia; na dosimetria da pena, requer a consideração dos maus antecedentes dos acusados, a aplicação da agravante da reincidência e a fixação de regime inicial fechado (fls. 420/432).

A defesa do réu Augusto, em seus memoriais, postula a absolvição por ausência de provas (fls. 456/459).

Por sua vez, a defesa do réu Rodrigo alega, preliminarmente, a nulidade da invasão de domicílio; no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas; subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial diverso do fechado (fls. 464/475).

É o relatório.

Decido.

De início, passo à análise da preliminar levantada pela defesa, qual seja, a de nulidade da busca e apreensão.

É certo que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, estabelece que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Entretanto, o delito de tráfico de entorpecentes, praticado nas modalidades "ter em depósito" e "guardar", é considerado crime permanente, de tal sorte que seu estado de flagrância se protraí no tempo (art. 303 do CPP). Sobre o tema, entendeu o C. STF, em repercussão geral, ser lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

No caso em comento, conforme depoimento das testemunhas, o réu Augusto foi encontrado em posse de droga e indicou aos policiais que estava transportando os entorpecentes que tinha buscado na casa de Rodrigo, havendo, portanto, fundadas

razões para o ingresso na residência. Entendo que também havia situação de urgência a justificar a entrada em domicílio, uma vez que o atraso decorrente da obtenção de mandado implicaria a destruição ou ocultação da prova do crime.

Não se desconhece o recente julgado do C. STJ no HC 598057/SP, no qual se entendeu que: "7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Todavia, o precedente não se aplica ao caso concreto.

Primeiramente, importante ressaltar que o caso em apreço se distingue daquele em que é necessário o consentimento para o ingresso em domicílio. Isso porque, na data dos fatos, havia razões devidamente justificadas que indicassem a situação de flagrante delito no interior da residência, bem como evidente urgência em face da possível destruição ou ocultação dos entorpecentes. Dessa forma, sequer era necessária autorização do(a) morador(a) para a entrada dos policiais no domicílio. Em segundo lugar, ainda que a situação fática fosse a mesma do julgado, o acórdão foi publicado com efeitos pro futuro, nos seguintes termos: "Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal".

Logo, rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e ausente, ainda, qualquer nulidade processual, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 07/09); termos de depoimento (fls. 10/14); termo de declarações (fl. 15); boletim de ocorrência n.º 584/2020 (fls. 17/21); termos de interrogatório (fls. 25/26 e 31/32); autos de exibição e apreensão (fls. 38/40); laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 48/60); fotografia (fl. 170); relatório final do inquérito policial (fls. 172/177); laudo pericial definitivo (fls. 251/253); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (tetrahydrocannabinol e cocaína, na forma de sal e de crack) se encontram expressamente previstas na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

A autoria dos acusados também está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

Em fase pré-processual, a menor Maria Eduarda, acompanhada de seu genitor, relatou o seguinte, conforme se extrai do termo de declarações de fl. 15:

"QUE CONHECEU RODRIGO DOMINGUES DE ALBUQUERQUE HÁ TRES MESES. QUE INICIARAM UM ROMANCE E LOGO JÁ FORAM MORAR JUNTOS. QUE A DECLARANTE SEMPRE SOUBE QUE RODRIGO MEXIA COM DROGAS, MAS QUE QUANDO FOI MORAR COM ELE PASSOU A AJUDA-LO. QUE A DROGA "PURA" (COCAINA), VEM DE BAURU. QUE O CRACK A DECLARANTE PESSOALMENTE FOI BUSCAR EM SÃO PAULO. QUE A DECLARANTE ERA QUEM FAZIA A "MISTURA" DE "TRETA, ACETONA E CAFEINA, PARA PREPARAR AS PORÇÕES. QUE NÃO VENDIAM DROGA "PICADA" NA PORTA DE CASA, NEM NA CIDADE, VENDIAM DE PACOTES DE UM QUILO, EM AVARÉ, ITAI, ITAQUAQUECETUBA E OUTRAS. QUE, A DROGA PURA ERA BUSCADA POR AUGUSTO PEDROSO, E TAMBÉM AS DROGAS JÁ PREPARADAS PRA VENDA, TAMBÉM ERAM LEVADAS POR AUGUSTO. QUE É MOTOBOY E RESPONSÁVEL POR TODAS AS ENTREGAS. QUE AUGUSTO ERA CONTRATADO DE RODRIGO. QUE NA MANHÃ DE HOJE

ESTAVA DORMINDO, E QUANDO ACORDOU VIU QUE AUGUSTO E RODRIGO PREPARAVAM A COCAÍNA PRA VENDA, USANDO O LIQUIDIFICADOR. QUE RAPIDAMENTE A DECLARANTE FOI ESCOVAR OS DENTES E LAVAR O ROSTO, E NESSE MOMENTO AUGUSTO SAIU COM A MOCHILA. QUE A DECLARANTE FOI ATÉ A PIA E COMEÇOU A LAVAR O LIQUIDIFICADOR, MOMENTO EM QUE OS POLICIAIS MILITARES CHEGARAM. ACRESCENTA A DECLARANTE QUE O LUCRO MENSAL É DE R\$25.000,00 QUE A DECLARANTE PRONTAMENTE NARROU TODO OCORRIDO. E CONTOU Á ELES QUE AUGUSTO PEDROSO JÁ ESTAVA EM PODER DE UMA QUANTIA DE DROGA. QUE ANTES DE SE ENVOLVER COM RODRIGO, A DECLARANTE JÁ VENDIA DROGA PARA UM TRAFICANTE DA VILA SANTA HELENA, O QUAL SE ENCONTRA PRESO. QUE É ENVOLVIDA COM VENDA DE ENTORPECENTE DESDE OS 14 ANOS DE IDADE. QUE NUNCA ESTEVE NA FUNDAÇÃO CASA, NEM SE ENVOLVEU EM OCORRENCIA POLICIAL".

Em juízo, a testemunha EMERCI APARECIDA SEBASTIAO, policial militar, declarou que receberam denúncia através do 190, informando que, em uma residência no bairro São Geraldo, havia grande quantidade de entorpecente; que a patrulha foi até o local e não localizou nada; que, mais tarde, a mesma pessoa ligou novamente e disse que estava saindo lá do São Geraldo uma motocicleta, cujas características descreveu, com grande quantidade de entorpecentes; que os policiais aguardaram passarem várias motocicletas, até que passou aquela com as características descritas pelo denunciante; que realizaram a abordagem do condutor, em cuja mochila havia cocaína e crack; que, indagado, o condutor disse que realmente estava nessa residência lá no São Geraldo, que passaria em sua própria residência para pegar maconha e que levaria a droga para uma mulher na Cohab II, em São Manuel. Contou que foram apreendidos com Augusto crack e cocaína que estavam prontos e embalados; que as drogas tinham até a marcação de seu peso; que no total a quantidade era próxima a 3 kg, 1,5 g de cocaína. Narrou que a sua patrulha foi à residência no bairro São Geraldo, ao passo que a outra - Cabo Cláudio e Cabo Bertoloto - foi à residência de Augusto, tendo encontrado a maconha nos locais por ele indicados. Disse que, quando chegaram à residência no bairro São Geraldo, o portão estava entreaberto, e havia uma mulher na garagem; que quando ela viu a aproximação da viatura ela saiu correndo; que, quando alcançada, disse que tinha ficado com medo, porque o marido dela tinha pedido a droga na parte da manhã juntamente com o rapaz da motocicleta; que ela ainda relatou que, no dia anterior, ela tinha ido de moto com ele para Bauru para buscar entorpecentes, porque eles vendiam tanto em São Manuel quanto em municípios vizinhos; que, de manhã, Augusto com Rodrigo e eles estavam "trabalhando" a droga na residência. Narrou que ingressaram na residência, onde encontraram petrechos, liquidificador cuja borda estava suja de cocaína, uma prensa, comprovantes de depósitos bancários. Disse que Maria Eduarda mencionou que os valores eram semanais e provenientes do tráfico de drogas. Relatou que Rodrigo alegou que era apenas usuário; que primeiro disse que conhecia o Augusto e depois disse que não. Indagada, respondeu que não conhecia nenhum dos réus dos meios policiais; que Maria Eduarda era adolescente de dezessete anos, e que só ficaram sabendo disso quando ela apresentou os documentos.

No mesmo sentido, a testemunha RICARDO DE SOUZA CUNHA, policial militar, contou que, pela manhã, quando a equipe recebeu uma denúncia via 190, tendo a patrulha - Cabo Cláudio e Cabo Bertoloto - estado no local e não encontrado nada de ilícito; que a denúncia não indicou o número da rua; que, durante o dia, houve uma ligação na sede da companhia, que narrou novamente denúncia de indivíduo transportando drogas; que foi feito patrulhamento com vista às características passadas; que o indivíduo foi abordado em uma motocicleta em uma das vias que dava acesso ao bairro citado no início do dia; que em sua mochila foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, sendo que tinha certeza que uma das substâncias era cocaína; que não conhecia o indivíduo, mas que seus colegas lhe contaram que ele era conhecido por tráfico. Relatou que indagado, o indivíduo disse que estava transportando o entorpecente e estava o levando para outro local; que perguntaram a residência de onde ele havia saído, e ele os acompanhou até a residência, onde foi encontrado um casal; que, feitas as buscas, apreenderam petrechos para o fim de tráfico, uma prensa, um liquidificador com resquícios de drogas. Disse que soube pelos outros policiais que a residência era usada para armazenamento de drogas, onde misturavam os entorpecentes com outros componentes para distribuição no município; que esse

não era o local onde vendiam as drogas, e sim onde misturavam. Indagado, disse que não se recorda se, chegando na casa do Rodrigo, havia alguém fora da residência. A testemunha CLAUDIO ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA, policial militar, contou que não participou da abordagem, mas que somente foi chamado para auxiliar a patrulha que compareceu à casa do réu Pedroso. Narrou que a viatura que fez o flagrante pediu apoio; que foram no São Geraldo, onde ocorreu o flagrante, “pegaram” o Pedroso e o levaram na viatura até a residência dele; que o pai dele deixou os policiais entrarem, porque o Pedroso mora nos fundos; que o próprio réu indicou onde estava a droga, dentro do guarda-roupas atrás de umas gavetas; que havia um tijolo de maconha; que pegaram a droga e foram se encontrar com a outra viatura. Disse que não indagou o acusado sobre a destinação da droga; que não conhecia os acusados nem a adolescente, mas que já tinha ouvido falar do Pedroso nos meios policiais. Narrou que algumas horas antes do flagrante, tinha ido à rua da casa do Rodrigo, porque havia denúncia de que Rodrigo estava traficando em uma casa na Rua Leonardo Marcolan, mas como passaram na rua, não tinham o número e estava tudo fechado, sendo que não podiam entrar sem mandado, fizeram o patrulhamento e encerraram a ocorrência; então já tinham indícios de que ocorria o delito. Indagado, disse que essa denúncia da manhã informou os nomes de Rodrigo e Augusto, bem como da namorada de Rodrigo.

Em seu interrogatório, o réu AUGUSTO JOSÉ PEDROSO narrou que trabalha como motoboy, quando foi abordado por uma moça de nome Cristiane para levá-la na Cohab III; que pegou a corrida; que, chegando lá, a moça lhe perguntou se não levaria uma mochila até a Cohab I; que perguntou o que se encontrava na mochila e que a moça respondeu que seriam drogas; que o acusado aceitou levar a mochila; que a moça disse que, chegando lá, iria receber o pagamento em drogas por uma moça loira, de blusa preta, de nome Tatiana. Relatou que foi abordado no caminho, foi feito o flagrante e o levaram dentro da viatura até o bairro São Geraldo, onde já havia uma diligência em andamento; que ficou uns 25 minutos dentro da viatura; que depois lhe levaram até a casa do seu pai; que entraram na casa do seu pai; que, chegando lá, entregou uma porção de maconha para os policiais que tinha guardada; que, chegando na delegacia é que foi informado que estava preso juntamente com o Rodrigo e com a Maria Eduarda; que não os conhecia.

Interrogado, o réu RODRIGO DOMINGUES ALBUQUERQUE também negou as imputações. Declarou que entraram na sua casa quando estava dormindo; que ingressaram na sua casa sem mandado; que não sabe por que entraram na sua residência; que não conhecia o acusado Augusto; que namorava Maria Eduarda há uns dois ou três meses e que ela morava consigo; que as declarações de Maria Eduarda são mentirosas; que acredita que, quando Maria Eduarda viu a situação com a polícia, ela deve ter inventado qualquer história para “se livrar” a qualquer custo, lhe prejudicando; que levaram o seu liquidificador e uma prensa; que é usuário de drogas, mas que nunca usava esses objetos para nada relacionado às drogas; que os recibos que foram encontrados na sua casa eram de valores baixos e referentes a aluguéis.

Ocorre que as alegações dos acusados não merecem prosperar.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal (CPP). Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Ademais, os depoimentos colhidos em juízo estão em plena consonância com o relatado em fase pré-processual pela adolescente Maria Eduarda, essa que narrou, inclusive com detalhes, a divisão de tarefas entre os componentes da associação para a prática de delitos de tráfico de drogas, sendo que a residência de Rodrigo era o

local onde as drogas eram fracionadas e misturadas com outros compostos e, depois de preparadas as porções, Augusto era o responsável pelo transporte dos entorpecentes.

Cabe consignar que os policiais só chegaram à residência de Rodrigo e de Maria Eduarda porque Augusto lhes dissera que estava saindo de lá para transportar os entorpecentes.

Nesse diapasão, tenho que as condutas dos réus de trazer consigo e ter em depósito drogas, para fins de tráfico, juntamente com adolescente, amoldam-se ao tipo penal do art. 33, caput, c/c art. 40, VI da LD. No ponto, irrelevante que as drogas somente tenham sido encontradas somente na residência de Augusto, e que os petrechos tenham sido apreendidos na casa de Rodrigo, uma vez que ambos concorreram para o delito, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal (CP).

Ressalto que a grande variedade e quantidade de drogas - 1578,43 gramas de cocaína, 981,16 gramas de crack e 938,39 gramas de maconha -, a maneira como estava acondicionada a droga - fracionada, numerada e pronta para comercialização -, os petrechos apreendidos - 01 (um) liquidificador com resquícios de cocaína, 01 (uma) prensa, 02 (dois) rolos de fita adesiva, 01 (um) copo plástico, 01 (uma) faca - a quantia em espécie de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) - bem como os depoimentos colhidos em juízo indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD).

Ademais, a conduta dos acusados de se associarem entre si e com adolescente, para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, subsome-se ao tipo do art. 35, c/c art. 40, VI da LD. A estabilidade e permanência da associação é incontestante frente à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, da qual se extrai que as denúncias anônimas mencionavam os nomes dos acusados conjuntamente e especificavam a motocicleta dirigida por Augusto, bem como a residência de Rodrigo; ademais, os depoimentos são corroborados pela narrativa da menor, que esclareceu com detalhes o modus operandi da associação.

Concorre a majorante do art. 40, VI, da LD em relação a ambos os crimes. Restou cabalmente comprovado que a prática do tráfico envolveu a adolescente Maria Eduarda, bem como que a menor fazia parte da associação constituída. Nessa toada, as penas dos delitos de tráfico e de associação serão aumentadas em 1/6, em razão da incidência da majorante do art. 40, VI, da LD, por não haver circunstâncias que justifiquem o aumento em patamar superior.

Importa ressaltar que não acarreta bis in idem a incidência simultânea das majorantes previstas no art. 40 da LD aos crimes de tráfico de drogas e de associação para fins de tráfico, porquanto são delitos autônomos, com momentos consumativos diversos, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente (HC 250455/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Julgado em 17/12/2015, DJE 05/02/2016).

Não é possível a condenação autônoma por corrupção de menores quando a prática dos delitos capitulados nos arts. 33 a 37 da LD envolvem criança ou adolescente. Diante do princípio da especialidade, aplica-se a causa de aumento de pena prevista na referida lei, nos termos do seu art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e, uma vez incidente a majorante, é inviável a concomitante condenação pelo tipo do art. 244-B do ECA, sob pena de incorrência em bis in idem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. 2. Não é cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem). 3. Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37),

pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 4. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei. 5. Recurso especial improvido. (STJ - RESp: 1622781 MT 2016/0226752-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2016) (grifei).

Opero a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para atribuir aos fatos a seguinte capitulação jurídica: arts. 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n.º 11.343/2006.

Não concorrem minorantes. Não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da LD em relação ao delito de tráfico, uma vez que os agentes são reincidentes; além disso, há prova segura a indicar que se dedicavam a atividades criminosas, já que atuavam em verdadeira associação criminosa, por lapso considerável de tempo, tanto é que estão sendo condenados, nesta sentença, também pela prática do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Nessa linha, a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a condenação pela associação ao tráfico é incompatível com a concessão da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (AgRg no RESp 1797518/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

Presente a agravante da reincidência em relação a ambos os réus (art. 61, I, e 63 do CP).

O acusado Augusto sofreu condenação com trânsito em julgado no processo n.º 0000133-79.2017.8.26.0573, pelo crime de furto qualificado, sendo que entre a data de extinção da pena e a dos fatos aqui processados não decorreu o lapso temporal de cinco anos (fls. 100/110).

O acusado Rodrigo, por sua vez, foi condenado com trânsito em julgado nos processos de n.º 0000039-65.2016.8.26.0574 e 0006667-94.2011.8.26.0073, ambos pelo crime de tráfico de drogas, sendo que entre a data de extinção das penas e a dos fatos aqui processados não decorreu o período depurador (fls. 113/115).

Por fim, tratando-se os delitos dos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 de condutas autônomas, com tipos penais distintos, bem como com elementares e momentos consumativos próprios, aplica-se entre eles o concurso material (art. 69 do CP), na esteira da jurisprudência do STJ (HC 135.207/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016).

Verifico que, na data dos fatos, os acusados eram imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude de seus comportamentos e lhes eram exigíveis condutas diversas. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os acusados efetivamente praticaram os fatos descritos na denúncia, razão pela qual devem responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria das penas.

1. Do réu AUGUSTO JOSÉ PEDROSO

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca aos tipos penais. O réu possui maus antecedentes, porque reincidente, mas deixo de valorá-los nesta fase para não incorrer em bis in idem (Súmula 241 do STJ). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois os crimes são vagos. A quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas negativamente em relação a ambos os delitos, aumentando-se a pena de cada um em 1/6, pois a quantidade total de droga é superior a três quilogramas e, além disso, foram apreendidos três tipos diferentes de entorpecentes, inclusive o crack, substância com efeitos especialmente deletérios e grande poder viciante. Assim, fixo as penas-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, para o crime de tráfico, e em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, para o delito de associação.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, e 63 do CP), em razão da condenação nos autos n.º 0000133-79.2017.8.26.0573 (fls. 100/110), razão pela qual agravo as penas em 1/6.

Ficam as penas provisórias em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, para o crime de tráfico, e em 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa, para o delito de associação.

Na terceira fase, presente a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente, aumento as penas em 1/6, chegando ao resultado de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa, para o tráfico, e em 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão e 1.110 dias-multa, para a associação.

Presente o concurso material (art. 69 do CP), somo as reprimendas.

Fica AUGUSTO JOSÉ PEDROSO definitivamente condenado a 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão e 1.903 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda e da reincidência em crime doloso.

2. Do réu RODRIGO DOMINGUES ALBUQUERQUE

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca aos tipos penais. O réu possui maus antecedentes, porque reincidente, mas deixo de valorá-los nesta fase para não incorrer em bis in idem (Súmula 241 do STJ). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois os crimes são vagos. A quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas negativamente em relação a ambos os delitos, aumentando-se a pena de cada um em 1/6, pois a quantidade total de droga é superior a três quilogramas e, além disso, foram apreendidos três tipos diferentes de entorpecentes, inclusive o crack, substância com efeitos especialmente deletérios e grande poder viciante. Assim, fixo as penas-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, para o crime de tráfico, e em 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, para o delito de associação.

Na segunda fase da dosimetria, o réu é duplamente reincidente em razão das condenações nos processos n.º 0000039-65.2016.8.26.0574 e 0006667-94.2011.8.26.0073 (fls. 113/115), motivo pelo qual elevo as penas em 1/5.

Ficam as penas provisórias em 7 anos de reclusão e 699 dias-multa, para o crime de tráfico, e em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 979 dias-multa, para o delito de associação.

Na terceira fase, presente a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, em razão do envolvimento de adolescente, aumento as penas em 1/6, chegando ao resultado de 8 anos e 2 meses de reclusão e 815 dias-multa, para o tráfico, e em 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão e 1.142 dias-multa, para a associação.

Presente o concurso material (art. 69 do CP), somo as reprimendas.

Fica RODRIGO DOMINGUES ALBUQUERQUE definitivamente condenado a 13 anos e 24 dias de reclusão e 1.957 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, a, do CP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda e da reincidência em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, com fulcro no art. 383 do CPP, para:

a) CONDENAR AUGUSTO JOSÉ PEDROSO, já qualificado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, à pena de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.903 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa;

b) CONDENAR RODRIGO DOMINGUES ALBUQUERQUE, já qualificado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, à pena de 13 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1957 dias-multa., no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Mantenho as prisões preventivas (art. 387, § 1º, do CPP), porquanto permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Ambos os réus são reincidentes e estão sendo condenados, nesta sentença, por dois delitos majorados pela participação de adolescente. Quanto a Rodrigo, é sua terceira condenação por delitos de drogas. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Expeçam-se guias de execução provisória. Custas pelos réus, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual gratuidade judiciária.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Como a quantia e os objetos apreendidos estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva – produto e instrumentos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida a quantia para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

Expeça-se certidão de honorários, caso os patronos dos réus tenham sido nomeados com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

a) oficie-se ao IIRGD, comunicando as condenações;

b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;

d) expeçam-se guias de execução definitiva;

e) após o cumprimento de todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intimem-se.

São Manuel, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA